

1501743-43.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... vendida e que era seu primeiro dia no tráfico.

Em juízo, narrou que estava difícil arrumar emprego, só conseguia "bicos" e sua esposa estava grávida. Confessou o tráfico, informando que praticou o crime por necessidade para pagar o aluguel. O outro réu é apenas morador e nada tem a ver com o tráfico. Tem condenação por roubo e já tinha cumprido a pena. Nada tem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501743-43.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501743-43.2022.8.26.0537 Controle nº 1299/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN CLÁUDIO DE LIMA JÚNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

LUIZ GUSTAVO DA SILVA SANT'ANNA e IVAN CLÁUDIO DE LIMA JÚNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 11:00 horas, na Avenida Maria Cândida de Oliveira, altura do n.º 831, Bairro Vila Nogueira, previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, adquiriram, ofereceram, tinham em depósito, guardavam e entregavam, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi concedida liberdade provisória ao acusado Ivan Cláudio na audiência de custódia, mediante a imposição de medidas cautelares e o recolhimento de fiança, arbitrada em R\$ 4.040,00 (fls. 55/60). A fiança arbitrada não foi recolhida.

A prisão em flagrante do réu Luiz Gustavo foi convertida em prisão em flagrante na

audiência de custódia (fls. 55/60). A prisão preventiva foi reapreciada, e mantida, por decisão de 21.10.22 (fls. 132).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 109/110), sendo recebida a denúncia em 21.10.22 (fls. 131). O réu Luiz foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais. Quanto ao réu Ivan que não compareceu à audiência, embora devidamente intimado e citado, foi decretada a sua revelia.

A Dra. Promotora de Justiça, nos debates orais, requereu a condenação dos acusados, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, a aplicação da redução do art. 33 e regime aberto para o réu Ivan, por ser primários; quanto ao acusado Luiz que seja afastada a redução do art. 33, § 4.º, por ser reincidente, com a fixação de regime fechado e a perda do dinheiro apreendido.

O Defensor Público requereu a absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Em caso de eventual condenação, requereu em relação ao réu Ivan requereu a desclassificação para o art. 37 e regime aberto ou em caso de condenação a redução do art. 33, § 4.º no máximo, fixação de regime aberto, com as substituições legais, por ser primário, e direito de recorrer em liberdade. Quanto ao réu Luiz Gustavo, requereu a compensação da confissão com a reincidência, aplicação do art. 387, §2.º, do CPP e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O réu Luiz Gustavo confessou a prática do crime na fase policial (fls. 20). Afirmou que estava vendendo drogas, que recebia R\$ 1,00 por cada unidade vendida e que era seu primeiro dia no tráfico.

Em juízo, narrou que estava difícil arrumar emprego, só conseguia "bicos" e sua esposa estava grávida. Confessou o tráfico, informando que praticou o crime por necessidade para pagar o aluguel. O outro réu é apenas morador e nada tem a ver com o tráfico. Tem condenação por roubo e já tinha cumprido a pena. Nada tem contra os policiais. Está arrependido e pede uma oportunidade.

O réu Ivan Cláudio negou a prática do crime na fase policial, mas não apresentou qualquer justificativa (fls. 25). Em juízo, não compareceu, sendo decretada a sua revelia.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/05), disseram que atuavam em operação de combate ao tráfico e diligenciaram até o local dos fatos em uma viatura descaracterizada. Relatavam que durante "campana" observaram os réus no ponto de tráfico e que presenciaram o acusado Luiz Gustavo se abaixar próximo a um veículo VW/Santana estacionado na via pública, pegar algo debaixo do veículo e entregar a um usuário. Então, resolveram abordar os réus. Narraram que ao perceber a presença deles o réu Ivan gritou "Moizou, polícia" para o acusado Luiz Gustavo, e ambos saíram correndo. Informaram que conseguiram deter os réus a cerca de 10 metros do ponto de tráfico. Falaram que o réu Ivan, quando tentava se evadir, caiu ao solo e se lesionou na testa, bem como que resistiu ao ser algemado, se debatendo, pelo que tiveram que usar de força moderada para contê-lo. Afirmaram que retornaram para o local em que os réus estavam traficando e localizaram em cima da roda dianteira do lado do passageiro do veículo VW/Santana, uma sacola contendo 20 porções de maconha, 24 porções de cocaína e 38 pedras de "crack", todas embaladas e individualizadas. Informaram que em busca pessoal no réu Luiz Gustavo, localizaram no bolso da jaqueta dele a quantia de R\$ 14,00. Disseram que encaminharam o réu Ivan para atendimento médico no Hospital Municipal de Diadema, onde foi dispensado por ordem médica, e então o conduziram ao distrito policial.

Pedro Paulo (policial), em juízo, narrou que o local é conhecido como ponto de tráfico, viram o réu Luiz pegando uma sacola e colocando na roda de um veículo Volkswagen, o réu Ivan estava perto daquele e aquele entregou algo a um usuário. Disse que, quando os avistou, o réu Ivan correu. Havia dinheiro com o réu Luiz e acharam a sacola com drogas (divididas em invólucros) na roda do veículo, que o viram mexendo. O réu Ivan estava junto com o corréu, olhou e gritou "molhou". O usuário se evadiu. Não conhecia os réus. Narrou que o réu Luiz confessou e o outro réu alegou que só estava na rua. Viram o réu Luiz entregando algo para uma terceira pessoa (usuário). Fizeram "campana", em uma viatura descaracterizada, por uns 5

minutos, há uma distância de uns 30 metros. Ivan caiu na fuga. Não conhecia os réus anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Cléber. O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

“PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação” (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). A quantidade (fls. 19 – 20 porções de maconha, 24 invólucros de cocaína e 38 pedras de “crack”) e a diversidade (maconha, cocaína e “crack”) de drogas apreendidas, que estavam divididas em invólucros, a apreensão de dinheiro, cuja procedência se não comprovou, as confissões informal, extrajudicial e judicial do réu Luiz Gustavo, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teriam como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

“Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização” (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

“Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio” (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

A confissão extrajudicial do réu Luiz Gustavo foi corroborada pelos depoimentos dos policiais, que presenciaram o acusado em atos de mercância e a apreensão de dinheiro em poder dele.

Quanto à negativa extrajudicial do acusado Ivan Cláudio, sem qualquer justificativa, está isolada nos autos, posto que alegou mas nada comprovou, conforme exige o art.156 do CPP. Ademais, estava junto com o outro réu em atividade típica de tráfico, pelo que não é caso de desclassificação para o crime do art. 37, observando, ainda, que a pena por tráfico privilegiado é mais benéfica para o mesmo.

A materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 12/18) e laudo definitivo (fls. 81/83).

Assim, impõe-se a condenação dos acusados que segundo consta dos autos, o réu Luiz Gustavo é reincidente (fls. 47/48 – proc. 29109-60.2016 – em livramento condicional – fls. 113/130) e o corréu Ivan Cláudio é primário (fls. 158/160).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que “a lei regulará a individualização da pena” e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

“O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)”.

Assim, a reincidência do acusado Luiz Gustavo será considerada como circunstância agravante.

Passo a individualizar a pena a ser aplicada aos acusados.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica dos réus. Não é caso de aumento da pena-base diante da variedade de drogas, uma vez que no caso em tela a quantidade apreendida é pequena (nesta

Comarca inferior a 100).

Compenso a reincidência e a confissão extrajudicial do acusado Luiz Gustavo, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu Luiz Gustavo não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o

decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

Quanto ao acusado Ivan Cláudio, diminuo a pena de 2/3, posto que o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, §4.º), observando, ainda, que o M.P. concordou com tal redução.

O regime inicial de cumprimento da pena para o acusado Luiz Gustavo será o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente por roubo (fls. 47/48 – proc. 29109-60.2016) e estava em livramento condicional quanto praticou o crime (fls. 113/130), demonstrando que não foi um fato isolado em sua vida. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de

familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 17.08.22 pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 16.08.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

O regime inicial de cumprimento da pena para o réu Ivan Cláudio será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO LUIZ GUSTAVO DA SILVA SANT'ANNA à pena de 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, à razão mínima, e IVAN CLÁUDIO DE LIMA JÚNIOR à pena de 1 (UM) ANO e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 166 (CENTO E SESENTA E SEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se acharem incursos no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos quanto acusado Luiz Gustavo, diante do montante da pena e uma vez que é reincidente (fls. 47/48 - proc. 29109-60.2016). O "sursis" também é incabível diante do montante da pena e por ser reincidente em crime doloso (art. 77, inc. I, do Código Penal).

Tendo em vista que o réu Luiz Gustavo foi preso em flagrante, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 55/60) e decisão de fls. 132, que a manteve nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (reapreciação a cada 90 dias), e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Em relação ao réu Ivan Cláudio, considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado Ivan Cláudio poderá recorrer em liberdade, porque respondeu o processo solto, é primário e após as substituições legais foram impostas apenas penas restritivas de direitos e multa.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por serem beneficiários da Assistência Judiciária

(art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 165), conforme prova produzida, é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Transitada esta em julgado, lancem-se os nomes dos acusados no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 65), providencie-se o necessário quanto ao perdimento do dinheiro, comunicando-se ao SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e efetuem-se os cálculos das multas, abrindo-se vista às partes.

Diadema, 22 de novembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA